

1023432-12.2022.8.26.0050

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Habeas Corpus - Cabimento

Magistrado: Celina Maria Macedo Stern

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: DIPO 4 - Seção 4.1.1

Data de Disponibilização: 10/10/2022

... seja compatível com a conduta do crime de tráfico de entorpecentes.

Ao contrário, dos autos extrai-se que o cultivo da planta decorre de razões médicas e humanitárias, conforme se depreende do relatório médico.

A documentação acostada aos autos indica a urgência e necessidade de obtenção da substância pelo paciente, assim como resta demonstrada sua boa-fé ao fazer uso do presente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

DIPO 4 - Seção 4.1.1

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº 1023432-12.2022.8.26.0050 - Lauda de

Processo Digital nº:

IP e Distrito Policial nº:

1023432-12.2022.8.26.0050

Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo ilustre advogado Lucas Barros Reetz, em favor do paciente PLINIO ZARZUR CURI contra ato iminente a ser praticado por autoridades não determinadas, visando à obtenção de salvo-conduto para que o paciente possa cultivar em seu domicílio a planta Cannabis Sativa para fins exclusivamente terapêuticos, bem como guardar e transportar a dose para consumo diário, e que as autoridades policiais se abstenham de investigá-lo ou prendê-lo por tal prática.

Para tanto, alegou na inicial (fls. 01/07), em síntese, que o paciente é acometido por crises epiléticas desde a infância, tendo recentemente desenvolvido Lúpus e Síndrome Antifosfolípide, além de possuir uma série de outros males que o levaram a estágio terminal. Aduziu que o uso da Cannabis Sativa foi o único meio encontrado para reduzir as crises epiléticas e será o único caminho para restabelecer seu apetite e seu sono e diminuir as duas dores crônicas, sobretudo diante dos procedimentos de quimioterapia e hemodiálise aos quais terá que se submeter. Segundo consta, em razão do quadro de epilepsia recorrente, teve prescrito o medicamento NABIX, derivado de Cannabis Sativa, cuja importação foi devidamente autorizada pela ANVISA (fls. 13/14). Juntou relatório médico do paciente, em que consta que é portador de epilepsia há 30 anos, possui trombozes arterial e venosa, além de ter realizado diversos procedimentos médicos para identificação do mal que o aflinge (fl. 08). Segundo consta, Plinio teve a recomendação específica de Nabix 1500 (50mg CBD/1,5mg THC/ml), dosagem de 1,0 ml uma vez ao dia, remédio receitado pelo Dr. José Renato Felix Bauab (CRM: 83614). Juntou documentos (fls. 08/17). O pedido liminar foi indeferido (fls. 18/19).

O impetrante apresentou relatório médico atualizado com indicação das doenças que o paciente possui (e respectivas CID), prescrição médica para produtos industrializados e extrato de Cannabis rica em THC e CBD, além de recomendação para o cultivo entre 50-100 plantas de Cannabis Sativa (fases inicial, vegetativa e flora) para tratamento durante 03 meses (fls. 23/29).

O Ministério Público opinou pela concessão da ordem de habeas corpus (fls. 32/38). É o relatório. Fundamento e decidido.

A ordem definitiva deve ser concedida.

Inicialmente, cabe ressaltar que, segundo definição da Organização Mundial da Saúde (OMS), droga é qualquer substância não produzida pelo organismo que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas causando alterações em seu funcionamento.

Por outro lado, é certo que a lista de Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão (CID-10), em seu capítulo V (Transtornos Mentais e de Comportamentos) inclui o uso de canabinóides.

Entretanto, algumas substâncias possuem efeitos terapêuticos e, assim, ao serem utilizadas para o tratamento de doenças, passam a ser consideradas medicamentos. A propósito, há legislação internacional a respeito da matéria. A Convenção Única sobre Entorpecentes, promulgada pelo Decreto nº 54.216/64, em seu preâmbulo, reconhece expressamente o uso médico dos entorpecentes como indispensável para o alívio da dor e do sofrimento e dispõe que medidas adequadas devem ser tomadas para garantir a disponibilidade de entorpecentes para tais fins. No mesmo sentido, a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas, incorporada no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 79.388/77, também estabelece que o uso de tais substâncias para fins médicos e científicos é indispensável e que a sua disponibilidade para esses fins não deve ser indevidamente restringida.

A Cannabis sativa, planta a partir da qual é feita a maconha, foi incluída como planta medicinal pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na Lista Completa das Denominações Comuns Brasileiras - DCB pela Resolução da Diretoria Colegiada RDC Nº 156, de 5 de maio de 2017.

Pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 17, de 6 de maio de 2015, a ANVISA permitiu a importação, em caráter de excepcionalidade, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde, de produto industrializado que possua em sua formulação o canabidiol em associação com outros canabinóides, dentre eles o THC.

Nesse passo, o canabidiol foi incluído na "Lista - C1 - Lista das outras substâncias sujeitas a controle especial", por alteração à Portaria/SVS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Posteriormente, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 327, de 09 de dezembro de 2019, a Anvisa definiu as condições e procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, bem como estabeleceu requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais de uso humano.

Já a Lei nº 11.343/06, no parágrafo único do artigo 1º prevê: "Para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União".

No artigo 66 preceitua: "Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1º desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998".

O artigo 2º, por sua vez, estabelece que: "Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar (...)" e, no parágrafo único do mesmo dispositivo legal, consta que "Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas."

Pois bem.

É incontroverso que PLINIO ZARZUR CURI se vê acometido das seguintes doenças: epilepsia, trombose arterial e venosa (fl. 08), síndrome do anticorpo antifosfolipidico, glomerulonefrite, plasmocitose na medula óssea, dor intensa limitante, disfunção sistêmica grave, ansiedade (F40.0), depressão (F33.0), fator reumatoide em alto títulos, anti-PR3 em altos títulos, indícios de Gamopatia monoclonal de significado renal, crioglobulinemia tipo II ou III, vasculite ANCA associada, CIDs (não necessariamente na mesma ordem) M31.3 / D89.1 / D47.2 / D68.8 / N17.0 (fls. 08, 27 e 29).

Depreende-se dos autos que, por tais motivos, após a realização de diversos tratamentos convencionais, foi prescrito por médico (fls. 09, 12, 23/26 e 28) o uso do extrato em gotas de Cannabis (CBD e THC), pomadas, extrato vaporizado e derivados da matéria prima pura, o que lhe trouxe significativos resultados positivos, conforme aponta relatório médico subscrito pelo médico Dr. Adolfo Almeida, CRM-RJ 5298545-7: "Paciente sob meus cuidados, 59 anos, encontra-se com o uso regular e controlado do extrato de Cannabis Sativa com melhora clínica dos transtornos associados ao quadro de síndrome do anticorpo antifosfolipidico com internações recorrentes, associado a quadro de glomerulonefrite, fatores reumatoide positivos e plasmocitose na medula óssea, com quadro de internações consecutivas e limitação funcional. Ausência de tratamento devido os altos custos da medicação para o quadro de síndrome do anticorpo-antifosfolipidio com internações recorrentes. Neste momento encontra-se internado para tratamento. O quadro atual está relacionado a questão de dor intensa limitante e Disfunção sistêmica grave. O mesmo relata melhora clínica através dos extratos de cannabis produzido pelo mesmo. Além disso apresenta aspectos psiquiátricos com transtorno de ansiedade (F40.0), Depressão (F33.0). Relata que antes do tratamento com a cannabis apresentava crises de ansiedade frequente que prejudicava suas atividades laborais. Após o início do tratamento com óleos e a matéria prima bruta vaporizada da cannabis sativa, com ótimos resultados no seu dia a dia. Associado a um transtorno de ansiedade e depressão, assim como distúrbios do sono associados ao quadro de dor limitante. Em tratamento com óleo e flores de Cannabis Sativa desde 2019 com boas respostas clínicas, relatado pelo mesmo, através do seu auto-cultivo e cursos de extração de cultivo. Os medicamentos apresentam muitos efeitos colaterais (alteração de libido, sono, apetite, humor, perda de produtividade). A cannabis além de reduzir os efeitos colaterais, apresentou desmame de medicação e melhora clínica gradual. Após meu acompanhamento, relata usar em casos agudos de insônia, dor, ansiedade, humor 1G vaporizada da matéria prima da cannabis com boa resposta clínica e utilização casual do extrato de Cannabis. Jamais apresentou sinais de toxicomania ou de intolerância ao uso Cannabis e seus derivados. Relata não ter condições financeiras de arcar com tratamento que tem o valor aproximado de 40.000,00 reais anuais e apresenta boa resposta ao tratamento já feito de forma irregular." (grifei, fl. 27).

Assim, foi prescrita continuidade do tratamento com plantas de Cannabis Sativa para produção da medicação em suas formas orais e inalatórias, contendo a indicação expressa do óleo rico em CBD e THC, entre outros canabinoides (fl. 27). O médico Dr. José Renato Felix Bauab, CRM-SP 83.614, já havia prescrito ao paciente o óleo de Cannabis industrializado Nabix 1500 (50mg CBD/1,5mg THC/ml), dosagem 1,0ml, uma vez ao dia (fl. 12).

Há, pois, indicação clínica e expressa recomendação médica para que o paciente continue utilizando o extrato caseiro e a matéria bruta da Cannabis, bem como demonstração de insuficiência de medicamentos tradicionais e alternativas terapêuticas convencionais disponíveis para a sua qualidade de vida, além de apresentação das vantagens medicinais do óleo caseiro, salientando que o cultivo próprio da planta com a produção do medicamento é a melhor opção disponível para atender às necessidades individuais do paciente, sob risco de comprometimento ainda maior de sua saúde, já bastante debilitada (fl. 29).

Pela análise do relato da inicial, em cotejo com os pareceres médicos acostados aos autos, há muitos anos o paciente suporta elevada carga de dor e sofrimento, sem que houvesse efetivo alívio ou retomada da qualidade de vida por intermédio dos

medicamentos tradicionais e alternativas terapêuticas convencionais disponíveis, o que se agravou diante do seu atual e delicado quadro clínico.

Registre-se que o paciente obteve autorização da ANVISA para importar medicamentos à base de substâncias extraídas na Cannabis sativa, ou seja, já houve reconhecimento de ser o caso do paciente uma situação excepcional (fls. 13/14). Portanto, diante dos documentos acostados aos autos, entendo que a pretensão do Impetrante é garantir ao paciente o direito à vida com melhor qualidade possível, possibilitando a ele o acesso a tratamento atual de maior eficácia e indicado pela medicina, e garantindo-lhe condições de vida digna com o mínimo existencial para uma vida saudável.

Por meio desta impetração, busca-se a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como dos direitos à vida e à saúde, os quais devem prevalecer sobre a proibição de se cultivar a planta de onde se extrai a substância utilizada especificamente para o tratamento da paciente, em um contexto de necessidade, adequação e proporcionalidade.

Ainda que a substância em questão conste da portaria Portaria SVS/MS nº 344, não pode o ato normativo afastar o direito à vida e à saúde do paciente, uma vez que, sem eles, não desfrutaria de nenhum outro.

A legislação que garante e regula o direito à saúde deve sempre se manter atenta para acompanhar os avanços da ciência e da medicina, atualizando-se e facilitando que o cidadão possa usufruir, na integralidade, do seu direito à saúde.

Outrossim, não se afigura coerente que a lei, cujo bem jurídico tutelado é a saúde pública, impeça a fruição plena deste mesmo direito. Por isso mesmo existe permissão legal para o cultivo da maconha para os fins específicos descritos no parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 11.343/06, ainda que não regulamentada. Não obstante, a inércia estatal em conferir eficácia a tal norma não pode servir de obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde e à própria dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, a concessão da ordem pretendida nada mais é do que a plena concretização da Justiça.

E não há qualquer tipo de indício, ou suspeita acerca da conduta do paciente, de que o ato de semear, cultivar e dispor da planta (maconha) seja compatível com a conduta do crime de tráfico de entorpecentes.

Ao contrário, dos autos extrai-se que o cultivo da planta decorre de razões médicas e humanitárias, conforme se depreende do relatório médico.

A documentação acostada aos autos indica a urgência e necessidade de obtenção da substância pelo paciente, assim como resta demonstrada sua boa-fé ao fazer uso do presente remédio constitucional para garantia judicial da pretensão e regularização da sua atual situação, em vez de permanecer na clandestinidade.

Outrossim, não se olvida que existem instrumentos legais para que o paciente receba auxílio estatal para a obtenção do medicamento à base de Cannabis por meio de determinação judicial à Fazenda Pública. No entanto, é de se considerar que os trâmites burocráticos e a morosidade para o alcance da pretensão justificam, no caso concreto, o pedido formulado para extração artesanal do óleo necessário, evitando-se ainda eventual interrupção do tratamento em virtude dos entraves para obtenção do medicamento. Ademais, no caso específico dos autos, a obtenção do óleo artesanal é benéfica e especificamente indicada ao tratamento.

No mais, a concessão do salvo-conduto ao paciente, por certo, não impede a responsabilização criminal em caso de eventual descumprimento da ordem judicial e desvirtuamento dos fins da autorização judicial que se destina única e exclusivamente para a realização do tratamento de sua saúde, incumbindo-lhe as consequências penais cabíveis.

Além do mais, é sabido que já há diversas decisões proferidas no Brasil que asseguram a inúmeros cidadãos a fruição de direito semelhante ao pleiteado nesta ação de habeas corpus, conforme se depreende, a título exemplificativo, dos seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus - Pleito de salvo-conduto a fim de garantir o plantio artesanal, para fins medicinais, de Cannabis Sativa, livre do risco de prisão. Paciente

portador de 'doença de Crohn' e 'fibromialgia', apresentando intenso sofrimento físico e psicológico em virtude de seu quadro de saúde. Paciente que se utilizou de diversos medicamentos para controlar e amenizar sua condição de saúde, os quais não tiveram os efeitos esperados ou eram de valor financeiro inacessível. Documentos médicos comprovando que a Paciente obteve melhora significativa com o uso terapêutico de Cannabis Sativa, orientando a continuação de seu tratamento. Necessidade comprovada, por indicação médica, para uso de medicamentos/óleos à base de Cannabis Sativa. Paciente que possui autorização de importação do produto pela ANVISA. Ordem concedida para expedição de salvo-conduto, nos termos deste voto." (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2225590-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020) (Grifei).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Habeas corpus preventivo impetrado em primeira instância - Cultivo de cannabis sativa para fins medicinais - Pretensão de expedição de salvo-conduto a fim de possibilitar que os recorrentes possam cultivar cannabis sativa, em sua residência, com o objetivo de obter o óleo terapêutico utilizado para o tratamento da sua filha, tratamento este indicado por médico devidamente registrado no CRM - Relatório indicando a eficácia da substância no caso concreto, havendo efetiva melhora no quadro clínico - Previsão legal quanto à possibilidade de cultivo de vegetais dos quais se possam ser extraídas drogas, desde que com finalidade medicinal ou científica, a teor do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06 - Matéria que ainda carece de regulamentação - Proteção do direito à saúde, que deve se sobrepor aos interesses secundários do Estado - Conduta que não se reveste de culpabilidade, de modo que não resta configurado ilícito penal - Inexigibilidade de conduta diversa - Segredo de Justiça que se faz necessário - Questão envolvendo interesse de incapaz, além de representar risco à segurança pública, caso seja publicamente conhecida - Recurso provido, a fim de conceder salvo-conduto aos recorrentes, para que possam cultivar, em seu domicílio, a planta cannabis sativa, com finalidade única e exclusiva de produzir o óleo terapêutico utilizado para o tratamento da sua filha, nos termos de sua prescrição médica, mediante o cumprimento das condições especificadas nesta instância." (TJSP - Recurso em Sentido Estrito 1016472-58.2020.8.26.0196; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020) (Grifei).

""Habeas corpus" preventivo. Cultivo domiciliar de "Cannabis sativa" para o tratamento medicinal dos filhos, portadores de Transtorno do Espectro Autista. Laudos médicos. Prescrição de óleo rico em canadibiol. Resultados promissores. 2. Substância regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Pendente regulamentação do cultivo domiciliar da planta para fins medicinais. Regulamentação, há mais de cinco anos, pelo Conselho Federal de Medicina. 3. Artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06. Possibilidade de plantio, cultura e colheita de vegetais dos quais possam ser produzidas drogas, desde que com fins medicinais ou científicos. 4. Circunstâncias concretas do caso que indicam que o comportamento não configura ilícito penal, por falta de culpabilidade. Inexigibilidade de conduta diversa enquanto fator supra legal de exclusão da culpabilidade. Ordem concedida." (TJSP - Habeas Corpus Criminal 2053254-53.2020.8.26.0000; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Campinas - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020) (Grifei).

Nesse ponto, vale ressaltar que, recentemente, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos de Habeas Corpus nº 1016472-58.2020.8.26.0196, o Desembargador Relator, Excelentíssimo Doutor Ricardo Sale Júnior, discorreu amplamente sobre as normativas legais concernentes à possibilidade de extração artesanal do óleo da Cannabis para fins medicinais, sendo

de suma importância a transcrição a seguir:

"Ocorre que, muito embora a possibilidade de autorização do plantio e cultivo de cannabis esteja prevista no ordenamento jurídico pátrio há mais de 40 (quarenta) anos, a questão segue sem regulamentação ou norma específica.

A partir da análise das normas acima transcritas, fica claro que a finalidade incriminadora da Lei nº 11.343/06 não busca albergar o cultivo de plantas, das quais possam se extrair drogas, com fim medicinal, na medida em que o bem jurídico tutelado pela respectiva norma penal visa à proteção da saúde pública, não tendo como escopo, portanto, prejudicar, de qualquer forma, a efetivação do direito fundamental à saúde, garantido pela Constituição Federal, como também não era esta a finalidade da revogada Lei de Drogas nº 6.368/76.

Em verdade, tais normas evidenciam que, há mais de 40 (quarenta) anos mais precisamente desde 22 de novembro de 1976, data em que a Lei nº 6.368/76 entrou em vigor, 30 (trinta) dias após sua publicação em 22 de outubro de 1976, nos termos do seu artigo 47 a União encontra-se em mora para regulamentar tal prática, sendo certo que a ANVISA, enquanto o órgão regulador competente para registrar produtos, substâncias e serviços que podem afetar a saúde da população, detém a competência para complementar a norma penal em branco, por meio de Resolução, porém não o fez até o presente momento.

Não se desconhece, por certo, que a proposta de plantio de cannabis sativa para fins medicinais foi rejeitada pela Diretoria Colegiada da ANVISA, a qual, após consulta pública, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 327, de 09 de dezembro de 2019, autorizou apenas a fabricação e a importação de produtos de Cannabis, excluindo, assim, a regulamentação do plantio do respectivo vegetal.

Ocorre que, a partir da leitura do parágrafo único do artigo 2ª, da Lei nº 11.343/06, conclui-se que o cultivo das plantas ali mencionadas, para fins exclusivamente médicos, não consiste em mera possibilidade do Poder Público, devendo ser interpretada como verdadeiro dever estatal de efetivação do direito fundamental à saúde daqueles que necessitam do referido tratamento, ante a ineficiência do tratamento médico convencional.

Este verdadeiro poder-dever do Estado para regulamentar a questão ora em debate pode ser extraído, também, a partir das Convenções Internacionais sobre drogas, das quais o País é signatário.

A Organização das Nações Unidas (ONU) possui três Convenções sobre tóxicos, que constituem, até hoje, os principais documentos internacionais de referências, servindo de baliza aos Estados-membros no momento de elaborar suas legislações internas sobre o tema.

A primeira delas é a Convenção Única sobre Entorpecentes, assinada em Nova Iorque em 30 de março de 1961, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 05, 07 de abril de 1964, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 54.216, de 27 de agosto de 1964, na qual se percebe o reconhecimento da comunidade internacional a respeito do perigo das substâncias psicoativas, considerando a toxicomania um mal grave para o indivíduo e um perigo social e econômico para a humanidade. Em que pese tal preocupação, nota-se, também, o reconhecimento do uso médico de substâncias entorpecentes, quando indispensáveis para o alívio da dor e sofrimento, prevendo medidas adequadas para que possa garantir a disponibilidade de sua utilização para tal desiderato medicinal³.

Registre-se, ainda, que o Diploma em questão, em seu artigo 49, inciso II, alínea "f", estabelece que "o uso da Cannabis para fins que não sejam médicos ou científicos deverá cessar o mais cedo possível, e, de qualquer, maneira, dentro de 25 anos a contar da entrada em vigor da presente Convenção", o que deixa claro, portanto, a finalidade de não proibição da utilização da referida substância quando utilizada com finalidade terapêutica.

Posteriormente, assinou-se a Convenção sobre Substâncias Psicotrópicas (Viena - 21 de fevereiro de 1971), aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 90, de 05 de dezembro de 1972, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 79.388, de 14 de março de 1977, na qual a comunidade internacional reconheceu que o uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e científicos é

indispensável, sendo que a disponibilidade de tais substâncias com essa finalidade não deve ser indevidamente restringida, trazendo, no bojo do seu artigo 5º, regras acerca da limitação do uso para fins médicos e científicos.

Por fim, os países signatários assinaram a Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, concluída em 20 de dezembro de 1988, em Viena, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 162, de 14 de junho de 1991, e promulgada pelo Decreto Presidencial nº 154, de 26 de junho de 1991. Muito embora neste documento não seja dado enfoque expresso à questão do uso de substâncias ilícitas para fins medicinais, terapêuticos ou científicos, é certo que, analisando-se o seu teor, constata-se o emprego reiterado da expressão "ilícito", a partir do qual se infere que, além das substâncias ilícitas, é possível haver, também, algumas empregadas com finalidade lícita (aqui compreendido o uso medicinal e terapêutico), alinhando-se, assim, aos anteriores diplomas internacionais sobre a matéria.

Dessa forma, à luz das normas internacionais sobre o tema, criadas justamente com a finalidade de repercutir no ordenamento jurídico interno dos países signatários, desponta nítido o entendimento de que o cultivo, bem como a utilização de substância extraída da cannabis sativa, com fim unicamente medicinal ou terapêutico, não pode ser inserida, de nenhuma forma, dentro das regras que buscam coibir, internacional ou nacionalmente, o tráfico ilícito de entorpecentes. Da mesma forma, a referida conduta também não pode ser equiparada àquela inserta no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, ou mesmo no artigo 33, caput, da referida legislação, eis que representaria legítimo descompasso com a própria finalidade da norma, mormente quando ela própria traz, em seu bojo, a possibilidade de se autorizar o plantio, cultura e colheita de cannabis, além de outros vegetais, exclusivamente para fins medicinais ou científicos."

A 10ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua vez, nos autos de Habeas Corpus nº 2211066-32.2018.8.26.0000, concedeu a ordem para beneficiar uma paciente com salvo conduto com validade de um ano, "a fim de que as autoridades encarregadas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal e/ou Guarda Municipal, sejam impedidas de proceder à prisão ou detenção da paciente pela produção ou plantação de cannabis sativa (maconha), em sua residência e que é exclusivamente destinada ao tratamento da filha (nome no original), ficando ainda vedada a apreensão de tais plantas."

Na ocasião do referido julgamento, o Desembargador Relator, Designado Excelentíssimo Doutor Carlos Bueno, ressaltou o papel do juiz na análise da questão:

"(...) A dignidade da pessoa humana, como princípio constitucional, não é, do ponto de vista formal, hierarquicamente superior aos demais princípios constitucionais. Entretanto, exige uma mais humana análise, vez que constitui o pressuposto de toda a ordem constitucional. O renomado professor Fábio Konder Comparato publicou artigo para a APAMAGIS: "o papel do juiz na efetivação dos direitos humanos", ed. 2.001, pg. 29. Examina com o brilho de sempre o conflito entre princípios jurídicos fundamentais. E realça: ao Judiciário é atribuída "a delicada e importante função de julgar, de acordo com os grandes parâmetros de moralidade e Justiça, estabelecidos pela consciência ética coletiva, e expressos no sistema vigente de direitos humanos". E fez algumas recomendações, sobre o tema: "na eventual colisão entre dois princípios para a solução da lide, o juiz deve preferir aquele cuja aplicação ao caso representa maior respeito à dignidade humana."

Aponto, ainda, que a ANVISA não regulamentou o plantio caseiro, sendo matéria objeto de debate, tanto que arquivada a Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada RDC, que tratava do plantio e cultivo de cannabis para fins exclusivamente medicinais e científicos (ANVISA, Processo SEI nº 25351.421833/2017-76, Voto nº 039/ 2019/ DIRE5/ ANVISA, Diretor Antonio Barra Torres), conforme mencionado pela Exma. Desembargadora Relatora Dra. Cláudia Fonseca Fanucchi, nos autos Remessa Necessária Criminal nº 1018724-84.2020.8.26.0050, em 02.12.2021 (fls.

260/261), não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa.

Conclui-se que é possível, excepcionalmente, para o caso específico e individual do paciente, a autorização para cultivo de Cannabis sativa com finalidade estritamente medicinal, permitindo-se a extração artesanal das substâncias necessárias à produção do óleo caseiro.

Todavia, há de se limitar a quantidade de plantas a serem cultivadas, uma vez que foi sugerido o estoque em margem discricionária muito grande (entre 50 e 100), sem justificativa suficiente para tanto. Nesse sentido, entendo que a quantidade deve ser o mínimo recomendado pelo profissional e que, em caso de qualquer necessidade de ampliação, o requerimento deverá vir acompanhado de parecer de especialista demonstrando que a quantidade anteriormente deferida é insuficiente para o tratamento específico do paciente. Já o frasco que poderá ser portado e transportado está limitado a 30ml, mesma quantidade do frasco industrializado prescrito (fl. 12).

Por fim, a autorização está limitada a esta Comarca, não podendo o cultivo se dar em qualquer outro lugar que não a residência do paciente localizada na Rua Desembargador Mamede, nº 423, Jardins, São Paulo/SP, conforme indicado na petição inicial (fl. 01), nos documentos médicos (fls. 08, 09, 12) e nos esclarecimentos prestados (fls. 43/55).

Diante do exposto, CONCEDO A ORDEM nos presentes autos de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente PLINIO ZARZUR CURI, a fim de que as autoridades de segurança pública sejam impedidas de proceder à prisão em flagrante do paciente pela produção artesanal de Cannabis Sativa em sua residência para fins estritamente medicinais em seu benefício ou pelo porte e transporte do extrato caseiro produzido para uso individual, bem como de apreender os vegetais mencionados.

Consigno que fica o paciente autorizado a semear e cultivar a planta apenas e tão somente em seu domicílio (na residência situada na Rua Desembargador Mamede, nº 423, Jardins, São Paulo/SP), e na quantidade de 50 plantas por ano (totalizando todos os estágios), autorizando-se o porte e transporte de um frasco contendo 30ml do extrato caseiro, também somente nesta Comarca de São Paulo/SP.

A presente decisão tem caráter personalíssimo. Desse modo, o paciente PLINIO ZARZUR CURI será o único beneficiado com o extrato produzido, não podendo ser concedido a terceiros.

Deverá o paciente informar imediatamente este juízo, em caso de eventual e futura desnecessidade da medida para o tratamento, não sendo a presente decisão uma autorização sem prazo. Assim, fixo o prazo de 1 (um) ano para que o paciente, nestes autos, apresente relatório médico atualizado que contenha a expressa indicação da necessidade de continuação do tratamento, a fim de obter a renovação do salvo-conduto.

Comunique-se à Autoridade Policial responsável pela circunscrição do local de residência do paciente, até para que tal cultivo possa ser fiscalizado pelas autoridades policiais.

Decorrido o prazo para interposição de recursos voluntários sem provocação das partes, submeta-se a presente sentença ao reexame necessário, remetendo-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do disposto no artigo 574, inciso I, do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

São Paulo, 10 de outubro de 2022.

Celina Maria Macedo Stern
Juíza de Direito

Documento assinado digitalmente nos termos da Lei nº 11.419/2006, conforme impressão à margem direita.